

1501523-30.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para uso pessoal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 154/169).

É o relatório. Decido.

2. A pretensão punitiva estatal é procedente, porquanto a materialidade delitiva dos crimes de roubo tentado e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501523-30.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501523-30.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176873/2022 - 02º D.P. OSASCO, 25861129 - 02º D.P.

OSASCO, 2176873 - 02º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Victor Hugo Martins da Silva Lomba

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO

Vistos.

1. VICTOR HUGO MARTINS DA SILVA LOMBA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigo 157 do Código Penal, na forma tentada, e 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, em concurso material de crimes, porque, em 30 de junho de 2022, por volta das 08h00, na Avenida Sarah Veloso, 1.142, nesta cidade e comarca, o Acusado teria tentado subtrair, com emprego de grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, em proveito próprio, um aparelho celular, avaliado em R\$ 750,00, de propriedade da vítima Patrícia Gonçalves, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

1.2. Consta, ainda, na peça acusatória, que na data e local dos fatos o Acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 16,16g (dezesesseis gramas e dezesseis decigramas) de cocaína, 10,52g (dez gramas e cinquenta e dois decigramas) de

maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Aduz a Acusação que, na data e local dos fatos, a Vítima estava em ponto do ônibus e o Réu se aproximou, fazendo menção de portar arma de fogo junto à cintura, anunciando o assalto e exigindo a entrega do celular, mas Policiais Militares, que estavam em patrulhamento, avistaram a cena e intervieram, detendo o Denunciados antes que estivesse em posse da res e, em revista pessoal, localizaram as drogas descritas na exordial acusatória.

1.3. O Réu ofertou resposta à acusação (fls. 94/96). Houve o recebimento da peça acusatória (fls. 103/105) e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 103/105), ocasião em que foi colhido o depoimento da vítima, de uma testemunha e o Acusado interrogado, bem como feito seu reconhecimento (fls. 135/139).

1.4. Encerrada a instrução criminal, a Ilustre Representante do Ministério Público de São Paulo pediu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia (fls. 142/150). A Douta Defesa, por seu turno, requereu a absolvição por deficiência probatória, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para uso pessoal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 154/169).

É o relatório. Decido.

2. A pretensão punitiva estatal é procedente, porquanto a materialidade delitiva dos crimes de roubo tentado e tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 24/28, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de avaliação (fls. 15), e pelos laudo periciais de fls. 30/33 e 91/93, corroborados pela prova oral produzida em juízo. A autoria também é certa e recai sobre o réu.

2.2. Com efeito, a vítima Patrícia Gonçalves contou que, na ocasião dos fatos chegou ao ponto de ônibus que existe na localidade por volta das 07h30, o Réu estava sentado como se fosse passageiro, por volta das 08h00, o ônibus ainda não havia passado, pegou o celular para ver utilizar um aplicativo e o Acusado se aproximou e lhe disse para passar o aparelho e para não gritar, encenando como se portasse arma de fogo, chegou ele a tocar no celular, mas não o puxou, porque foi abordado por Policiais. Afirmou que acompanhou a revista pessoal feita no Réu e que viu quando os Policiais encontraram as drogas em sua posse, dentro da calça que usava, e não ouviu VICTOR HUGO dizer que os entorpecentes seriam destinados para uso próprio. Por fim, asseverou que se lembra da fisionomia do Acusado, que é branco, usava boné no dia dos fatos e tinha cabelos grandes.

2.3. A testemunha Diego Felipe Scorsi Prado contou que, no data indicada na denúncia, estava em patrulhamento na avenida dos fatos, avistou o Réu tentando subtrair o celular da Vítima, ao abordar o Acusado, encontrou a droga em sua posse em uma sacola embaixo de sua blusa, a qual seria destinada à mercancia ilícita.

2.4. Por fim, informado acerca de sua garantia individual ao silêncio, VICTOR HUGO MARTINS DA SILVA LOMBA preferiu nada manifestar.

2.5. Nesse contexto, não recai dúvida razoável sobre o noticiado e demonstrado roubo tentado, uma vez que, buscando o Increpado subtrair o aparelho celular da Vítima, atuou com grave ameaça, fingindo estar na posse de arma de fogo, não se consumando o delito patrimonial por circunstâncias alheias à sua vontade, vale dizer, a atuação dos Policiais Militares que presenciaram os fatos. E, naquela ocasião, foram encontrados estupefacientes na posse do Réu, destinados à mercancia, o que se extrai do seu interrogatório policial (fls. 10/11) e da versão apresentada na solenidade designada para instrução e julgamento pela testemunha Diego Felipe (fls. 137).

2.6. Em todo caso, saliento que o flagrante é forma de demonstração de materialidade e autoria, eis que "duas são as justificativas para a existência da prisão em flagrante: a reação social imediata à prática da infração e a captação, também imediata, da prova" (in Vicente Grecco Filho, Manual de Processo penal, 11ª edição, Ed. Saraiva, 2015, p. 313).

2.7. Outrossim, em juízo, o agente policial reiterou o quanto narrado em sede policial e que interesse algum teria em prejudicar o Réu, imputando-lhe falsamente o cometimento de crimes tão graves (fls. 03/04). Impõe-se ressaltar que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente

desprezado, de modo que não é crível imaginar que o policial ouvido no curso da fase instrutória e perante o Magistrado iria apresentar versão fantasiosa dos fatos 2.8. Impende ressaltar que, “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJSP, Apelação nº.0002713-11.2014.8.26.0081, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel Des. Grassi Neto, julgado em 17/08/2017).

2.9. Logo, o quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática dos delitos de roubo tentado e de tráfico de drogas. Ademais, observa-se que a forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, permitem o reconhecimento do delito acima.

2.10. Desta feita, sendo certas as materialidades delitivas, bem como a autoria por parte do Acusado, ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, passo à dosimetria da pena a ser imposta.

2.11. Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, vê-se que o Acusado não possui Maus antecedentes (fls. 39/45) e que as demais circunstâncias lhes são favoráveis ou neutras. Portanto, fixo as penas-bases nos mínimos previstos nos preceitos secundários dos tipos penais incriminadores, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; e em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de roubo.

2.12. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Por isto, as penas intermediárias devem ser mantidas nos mínimos legais.

2.13. Na terceira fase, ausentes causas de aumento, mas reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista a primariedade do agente, a pequena quantidade de estupefacientes apreendidos pelos agentes policiais (35 porções de cocaína e 6 de maconha, de acordo com o auto de exibição e apreensão de fls. 13/14) e não haver condenações transitadas em julgado ou outros elementos a indicar ser VICTOR HUGO integrante de facção criminosa ou que se dedique a atividades criminosas. Portanto, não há motivos que impeçam a redução no máximo legal de 2/3 (dois terços) para a fixação da reprimenda definitiva pelo crime de tráfico de drogas, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um no piso legal à míngua de elementos que indiquem a situação financeira do Increpado.

2.14. Com relação ao crime de roubo, há que ser reconhecida a causa de diminuição de pena referente à tentativa (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal), de modo que, ante a versão apresentada, de que o Increpado apenas tocara no celular que seria subtraído, não fosse a pronta atuação dos agentes policiais que realizavam patrulha ostensiva nas imediações, o iter criminis apenas se iniciou, razão pela qual a redução deve se no máximo legal, ou seja, em 2/3 (dois terços). Desta maneira, a reprimenda definitiva pelo crime de roubo tentado deve ser fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, cada um no piso legal à míngua de elementos que indiquem a situação financeira do Increpado.

2.15. Ante a ocorrência do concurso material de crimes, as penas devem ser somadas.

2.16. Tendo em vista a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº. 8.072/90, ou seja, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado, assim incidentalmente declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, porquanto “a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena” (STF, Habeas Corpus nº. 27/06/2012, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/06/2012), a quantidade da pena corporal imposta, a primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é forçosa a imposição do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal.

2.17. Outrossim, é de se observar que o Pretório Excelso, no recente julgamento do

HC nº. 118.533/MS (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 23/06/2016), firmou o entendimento de que “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos”; logo, “o tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo como organização criminosa”. De seu turno, o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça” (Pet nº. 11796/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 23/11/2016), aderiu à tese fixada pela Suprema Corte e cancelou o enunciado nº. 512 de sua súmula.

2.18. No presente caso, a pena corporal fixada para o crime de tráfico de drogas pode ser substituída por restritiva de direitos, haja vista que o denunciado preenche os requisitos previstos nos incisos do artigo 44 do Código Penal, ou seja, a pena privativa de liberdade não excede a 4 (quatro) anos, o crime ao qual condenado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o Réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais são a ele favoráveis, de forma a indicar ser essa substituição suficiente para reprovação e prevenção do delito. Restando a pena definitiva em patamar superior a 1 (um) ano, substituo a pena corporal por: (a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em atividade compatível com a aptidão pessoal do Réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada no curso da execução do título judicial, e (b) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 01 (um) salário mínimo a entidade beneficente que será designada pelo MM. Juízo da execução criminal, ex vi dos artigos 43, caput, incisos I e IV, e parágrafo 2º, in fine, 45, parágrafo 1º, e 46, do Código Penal.

2.19. Entretanto, com relação à pena aplicada ao roubo tentado, haja vista que o tipo se adequou formalmente à conduta imputada ao Inculpado com a grave ameaça empregada, por meio da simulação de porte de arma de fogo, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Entretanto, possível a concessão do sursis, nos termos do artigo 77 do Código Penal. Isso porque deve ser observada a regra inscrita no artigo 69, parágrafo 1º, do Estatuto Repressivo.

2.20. Para tanto, determino a suspensão da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o Sentenciado observar as seguintes condições: a) no primeiro ano, deverá prestar serviços à comunidade, nos moldes do art. 46 do Código Penal, à entidade a ser designada pelo MM. Juízo da Execução Criminal; b) cumulativamente, durante todo o período da suspensão, deverá pedir autorização para ausentar-se desta Comarca e comparecer pessoalmente, mensalmente, em Juízo para informar e justificar suas atividades.

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado VICTOR HUGO MARTINS DA SILVA LOMBA, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a se iniciar no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes no valor mínimo legal; substituo a pena corporal por restritivas de direitos, consistentes em (a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, à razão de uma hora por dia de condenação, e (b) prestação pecuniária consistente equivalente a 01 (um) salário mínimo. E como incurso no artigo 157 c.c. com o 14, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a se iniciar no regime aberto, sendo a pena corporal suspensa na forma e com as condições acima indicadas, e ao pagamento de 3 (três) dias-multa, no mínimo legal.

3.2. Condeno, ainda, o Réu ao pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608/2003, ressalvada a hipótese prevista no artigo 2º da Lei nº 1.060/50.

4. O Acusado poderá recorrer em liberdade, porquanto ou a pena aplicada diverge da privativa de liberdade ou foi ela suspensa, de modo que ausentes os requisitos

ensejadores da aplicação da cautelar extrema. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

5. Transitada em julgado, adote-se as seguintes providências: 1) Comunique-se ao MM. Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil; 2) Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao MM. Juízo da Execução Criminal, conforme artigo 105 da Lei nº. 7.210/84.

5.2. Se a parte acusada houver sido condenada ao pagamento da pena de multa e da taxa judiciária, intime-a para, no prazo de 10 (dez) dias, recolha os mencionados valores, sob pena de inscrição em dívida ativa (artigo 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao MM. Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento a Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o artigo 482, parágrafo 1º, das NSCGJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Osasco, 06 de setembro de 2022

RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA